

《【문제2】 A회사는 정보통신산업 등을 영위하는 회사인데, 2011. 10. A회사의 플랫폼 사업 부문이 분할되어 B회사가 설립되었다. A회사는 B회사의 주식 98.1%를 보유하고 있다. B회사는 2016. 12. 31. 기준 1조원이 넘는 자산과 독립적인 운영조직을 갖춘 회사이다. A회사는 B회사의 플랫폼 관련 전문성과 A회사의 마케팅 경쟁력을 결합한 신규 사업인 플랫폼을 기반으로 한 쇼핑, 미디어, 요식사업을 진행하였는데, 그 과정에서 B회사로부터 다수 근로자를 전출받았다. 한편 근로자 丙은 2015. 3. B회사에 입사한 직후 A회사의 플랫폼을 기반으로 한 쇼핑, 미디어, 요식사업으로 전출되어 관련 업무를 수행하였다. 위 전출과 관련해 A회사는 B회사와 B회사는 전출 근로자를 고용한 사업주로서 전출 근로자와 근로관계가 있음을 보증하고 임금 지급 등 근로관계 법령상의 사용자책임을 부담하며, A회사는 B회사가 전출 근로자와의 근로관계를 유지하기 위해 소요되는 인건비를 6개월마다 정산하여 B회사에 지급한다.는 내용의 비용정산 계약을 체결하였다. 위 계약에 따라 B회사는 근로자 丙을 비롯한 전출 근로자들에게 임금을 지급하였고 A회사는 B회사에게 전출 근로자들의 임금 상당액을 지급하였다. 2017. 7. 플랫폼을 기반으로 한 쇼핑, 미디어, 요식사업이 종료되자 丙을 비롯한 B회사의 전출 근로자들은 B회사로 복귀하여 플랫폼 사업 업무를 담당하였다. 근로자 丙은 A회사가 자신을 직접고용 하여야 할 의무가 있다고 주장한다. 근로자 丙의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 근로계약관계의 실질적 사용자 및 계약의 형태(도급, 전적, 파견)에 따른 직접고용의무 판단

**I. 문제 제기**

- 본 사안에서 A회사는 B회사의 자회사로서, B회사가 전출한 근로자 丙을 비롯한 다수 근로자들로부터 근로를 제공받았다. 형식상 丙은 B회사의 근로자였고, B회사가 임금을 지급하였다. 그러나 丙은 A회사의 신규 사업에 투입되어 A회사의 사업을 위한 업무를 수행하였다. 丙은 이러한 사정에 기초하여 A회사가 자신을 직접고용하여야 한다고 주장한다. 쟁점으로 丙의 전출 근무가 도급 내지 전적의 형태인지 아니면 불법파견에 해당하는지, 나아가 A회사에 직접고용의무가 발생하는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이와 같은 쟁점과 관련한 근로자 丙의 주장의 타당성에 대해 논한다.

**II. 불법 파견의 의의**

**1. 근로자파견의 개념**

- 파견근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '파견법') 제2조 제1호에 의하면, 근로자파견이란 파견사업주가 근로자를 고용한 후 그 고용관계를 유지하면서 사용자업주의 지휘·명령을 받아 사용자업주를 위한 근로에 종사하게 하는 것을 말한다. 즉, ① 고용관계는 파견사업주와 존속하면서, ② 실질적 지휘·명령권은 사용자업주가 행사하는 구조가 전형적인 근로자파견에 해당한다.

**2. 도급 및 전적과의 구별**

- 근로자파견과 도급 또는 전적을 구별하는 기준은 실질적 지휘·명령관계의 존재 여부이다. 도급은 수급인이 독립적인 사업주로서 자기 책임과 계산하에 업무를 완수하는 것으로, 사용자업주는 근로자에 대한 직접적 지휘·명령권을 행사하지 않는다. 전적은 근로자가 원래 소속을 이탈하여 다른 사용자에게 고용관계가 이전되는 것이며, 전적이 유효하려면 근로자의 동의가 필요하다. 반면, 근로자파견은 형식적으로는 소속 회사에 고용되어 있으나 실질적으로는 타 회사의 지휘·명령 아래 근로를 제공하는 경우를 의미한다.

**3. 불법파견과 직접고용의무**

- 파견법은 원칙적으로 제조업의 직접생산공정 업무 등 일부 업종에 대해서는 파견을 금지하고 있으며, 허용되지 않는 업무에 근로자파견이 이루어진 경우 불법파견으로 본다. 불법파견의 경우, 파견법 제6조의2에 의거하여 사용자업주는 해당 근로자를 직접 고용할 의무를 부담한다. 또한 대법원도 불법파견이 인정되는 경우 사용자업주와 근로자 사이에 직접 근로계약이 성립된 것으로 본다.

**III. 사안의 적용**

**1. 형식적 근로관계**

- 근로자 丙은 B회사의 근로자로 입사하여 B회사로부터 임금을 지급받았다. A회사와는 형식상 근로계약 관계가 없었으며, A회사는 B회사와 인건비 정산 계약을 체결하는 방식으로 비용만 부담하였다.

**2. 실질적 지휘·명령 관계**

- 그러나 丙은 B회사가 아니라 A회사의 신규 사업(플랫폼 기반 쇼핑, 미디어, 요식사업)에 투입되어 A회사의 필요에 따라 업무를 수행하였다. A회사가 직접 丙의 업무내용과 수행방식에 관여하고 지휘·명령을 행사하였을 것으로 보인다. 이는 전형적인 근로자파견의 실질을 가진다.

**3. 도급 또는 전적 여부**

- 도급으로 보기는 어렵다. B회사가 독립적 사업주로서 자기 계산으로 업무를 수행한 것이 아니라, 단순히 인건비만을 A회사에 청구하는 구조였기 때문이다. 전적의 경우에도 근로자 丙의 소속이 완전히 A회사로 이전되지 않았고, 임금은 여전히 B회사가 지급하였다. 따라서 전적에도 해당하지 않는다.

**4. 불법파견 여부**

- A회사는 정보통신 및 플랫폼 관련 사업을 영위하고 있었으며, 丙이 수행한 업무는 A회사의 핵심 사업에 해당한다. 이는 도급으로 볼 여지가 없고, 실질적으로 A회사가 지휘·명령권을 행사하였다면 불법파견에 해당한다. 또한 A회사가 속한 업종은 원칙적으로 근로자파견 허용 대상이 아닐 뿐 아니라, 이 사건에서 파견사업주(B회사)는 파견사업을 전문으로 하는 사업주가 아니므로, 합법적 파견으로 평가될 수도 없다. 따라서 이는 불법파견으로 귀결된다.

**5. 직접고용의무**

- 불법파견이 성립하면 A회사는 파견법 제6조의2에 따라 丙을 직접 고용하여야 할 의무를 부담한다. 따라서 丙이 A회사를 상대로 직접고용을 주장하는 것은 법리에 부합한다.

**IV. 결론**

- 근로자파견은 형식상의 고용관계와 달리 실질적으로 사용자업주의 지휘·명령 아래 근로가 이루어지는 경우 성립한다. 본 사안에서 丙은 B회사의 근로자로 입사하였으나, 실제로는 A회사의 신규 사업 업무에 투입되어 A회사의 지휘·명령을 받았다. 이는 도급이나 전적이 아닌 근로자파견에 해당하고, 파견법상 요건을 충족하지 못하므로 불법파견으로 평가된다. 그 결과 A회사는 파견법 제6조의2에 따라 丙을 직접 고용할 의무를 부담한다. 따라서 丙의 주장은 타당하다.